

1501756-78.2019.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501756-78.2019.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501756-78.2019.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELA RODRIGUES RAMOS e outro

Juiz de Direito: Dr.LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de GABRIELA RODRIGUES RAMOS e EDEMIR GONZAGA BATISTA NETO, dando-os como incursos nos artigos 33, caput c/c artigo 40, III, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 "caput" do Código Penal.

Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na manhã de 7 de dezembro de 2019, por volta das 08h00min, no Centro de Detenção Provisória "Asp Valdecir Fabiano", na cidade de Riolândia, comarca de Paulo de Faria, GABRIELA RODRIGUES RAMOS, qualificada a fl. 4, agindo em concurso, previamente ajustada e em unidade de desígnios com EDEMIR GONZAGA BATISTA NETO, qualificado a fls. 66-67, trazia consigo e ocultava para fins de tráfico 39,32g de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida como, maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15 e laudo pericial de fls. 72/74). Segundo se apurou, a denunciada Gabriela ocultou a porção da droga mencionada acima, no cós da calça e tentou entrar no presídio com ela para entregá-la ao denunciado Edemir. Ocorre que, durante a revista de praxe, no momento em que

a denunciada passou pelo scanner corporal, os agentes penitenciários viram na imagem que havia algo na região da cintura. Efetuada revista pessoal, constatou-se que a denunciada tinha em sua posse 39,32g de maconha. A quantidade de droga apreendida, a maneira como estava acondicionada e as circunstâncias da prisão, denotam que a mercadoria se destinava ao tráfico no interior do estabelecimento prisional. Os denunciados agiram em concurso de pessoas, pois a droga seria entregue por Gabriela ao denunciado Edemir, que a venderia no local. Ante o exposto, denuncio GABRIELA RODRIGUES RAMOS e EDEMIR GONZAGA BATISTA NETO como incurso nos artigos 33, caput c/c artigo 40, III, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal. Requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei nº 11.343/2006, notificando-se os acusados para o oferecimento de defesa prévia, seguindo-se com o recebimento da denúncia, citando-os e intimando-os para o interrogatório e instrução, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se até a final condenação."

Os acusados foram citados e apresentaram defesa prévia em fls. 174-181.

A denúncia foi recebida em fls. 183-186.

Realizada audiência de instrução no dia 22 de novembro do ano de 2021, foram ouvidas as testemunhas de acusação, Jurandir Barros Araujo Junior, Walmur Lopes Silva, Neis Kalixto Borges Junior e Marcelly Cavallini Soato Lima, bem como as testemunhas de defesa Tiago Barsanulfo Dos Santos e Jéssica Nascimento Felipe. Por fim, os acusados foram interrogados.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a procedência dos pedidos, nos termos da denúncia, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, o afastamento do tráfico privilegiado e o regime inicial fechado para cumprimento inicial da pena.

A Defesa requereu a absolvição por ausência de provas, aduzindo que a versão acusatória vem encampada apenas em elementos probatórios relacionados aos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários. Postulou pelo reconhecimento da coação moral irresistível e afastamento do art. 29 do CP, dada a ausência de liame entre as condutas dos corréus. Em caso de procedência, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), depoimentos e interrogatórios (fls. 2, 3, 4), Boletim de Ocorrência (fls. 12-14), Autos de Exibição e Apreensão (fl. 15) e Laudo Pericial (fls. 22-24), que apresentou resultado positivo para maconha em todas as amostras colhidas de dois tabletes envoltos por plástico transparente, possuindo a massa líquida de 33,6 gramas.

Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação.

A testemunha Jurandir Barros Araújo Junior, agente penitenciário, relatou que no dia do ocorrido disse que estava junto com a agente Marcelly quando foram passar a acusada pelo scanner corporal. A agente Marcelly visualizou uma imagem sobreposta nas vestes da acusada. Afirmou que ao indagaram a acusada sobre o que poderia ser, a mesma confessou que estava portando drogas. Afirmou que as drogas seriam para ser entregues nas mãos do acusado Edemir. Afirmou que na posse da acusada foi encontrada uma carta, que continha orientações de como era para proceder para poder entrar com drogas dentro da unidade, bem como informações financeiras da facção criminosa. Questionada, confirmou seu depoimento prestado em sede policial.

A testemunha Marcelly Cavallini Soato Lima, agente penitenciária, aduziu que estava operando o aparelho de scanner, e no momento em que a acusada passou, verificou que havia alguma coisa em sua cintura. Afirmou que dava para ver que era alguma coisa quadriculada. Afirmou que indagou a acusada e pediu que a mesma retirasse o volume. Aduziu que a acusada retirou o volume e mostrou para a depoente o que era. Afirmou que ao questionar a acusada, a mesma aduziu que recebeu essa droga de outra pessoa,

mas não quis informar quem era. Afirmou que a acusada comentou que estava portando a substância para quitar uma dívida de seu companheiro. Questionada se a acusada teria lhe dito o nome da pessoa que havia entregue as substâncias entorpecentes, aduziu que não se recorda, mas confirmou seu depoimento prestado em sede policial. A testemunha Walmur Lopes Silva, diretor do CDP, afirmou que não estava no CDP no dia dos fatos. Afirmou que no dia seguinte tomou conhecimento da ocorrência. Confirmou que teve apuração disciplinar para apurar a conduta do acusado Edemir. Questionado, afirmou que não tem conhecimento da versão apresentada pela acusada quando flagrada na posse dos entorpecentes. Questionado, aduziu que lhe foi informado que foi tentado adentrar no estabelecimento substâncias entorpecentes. Disse que a acusada teria sido interpelada e em seguida chamada a autoridade policial e tomadas as providências.

A testemunha Neis Calixto Borges, diretor de disciplina do CDP, afirmou que a acusada Gabriela passou pelo scanner corporal, momento em que a funcionária viu uma imagem que não era normal. Aduziu que a funcionária teria questionado a acusada se a mesma estava trazendo alguma coisa que não podia, momento em que a acusada mostrou para a funcionária o que estava portando as substâncias. Questionado, afirmou que não sabe para quem as substâncias seriam entregues, mas tomou conhecimento que a acusada iria visitar seu marido.

A testemunha Jéssica do Nascimento Felipe, afirmou que ficou sabendo dos fatos posteriormente. Disse que nunca ficou sabendo de nada parecido que teria havido antes com a Gabriela. Aduziu conhecer a acusada Gabriela há aproximadamente sete anos. Afirmou que a acusada trabalha como manicure no salão e trabalha até hoje no salão de beleza.

A testemunha Tiago B. dos Santos, afirmou que conhece o acusado Edemir, e sabe que o mesmo é pessoa trabalhadora, que sempre foi bom pai. Afirmou que conhece o Edemir há aproximadamente dez anos, e que ficou surpreso com sua prisão.

Interrogada, a acusada Gabriele negou a prática dos fatos. Aduziu que foi abordada por uma pessoa chamada Mirian, que pediu para que a acusada entrasse na unidade com as substâncias entorpecentes, e que no interior seria identificada por terceira pessoa. Disse que foi abordada na fila da entrada do presídio e que as drogas foram entregues no banheiro que existe na entrada do presídio. Afirmou que não teve escolha e que teria tentado adentrar no estabelecimento para levar as substâncias e quitar uma dívida de seu esposo. Afirmou que não verificou as informações que constavam na carta que portava. Afirmou que os agentes penitenciários não se preocuparam em diligenciar sobre quem teria entregue as substâncias para a depoente. Por fim, questionada pelo Ministério Público, aduziu que não conhecia a pessoa chamada Mirian.

O acusado Edemir aduziu que tomou conhecimento do que havia acontecido, posteriormente, por meio de sua esposa, que lhe contou que uma pessoa havia se aproximado e afirmado que a corré deveria entrar no estabelecimento portando substância entorpecente. Confirmou que possuía uma dívida interna decorrente de apostas de jogos de xadrez e futebol. Negou conhecer a pessoa conhecida como Mirian, bem como desconhece o teor da carta que estava na posse da corré. Diante dos elementos probatórios encartados aos autos, adianto que a pretensão punitiva é procedente.

Destaco, inicialmente que os depoimentos dos agentes penitenciários retro transcritos se revestem de inequívoca validade, eis que colhidos em juízo, sob o manto do princípio constitucional do contraditório e em estrita observância do devido processo legal. Ademais, os agentes não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício das funções. Assim cumpre dar validade aos depoimentos das testemunhas de acusação inquiridas no curso da instrução criminal. Essa é a orientação que se colhe da jurisprudência, como se infere da leitura da ementa do aresto que segue, in verbis:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob

o crivo do contraditório. (...). (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017);

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016);

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS PROVA SUFICIÊNCIA Materialidade e autoria comprovadas Apelante flagrado no momento em que entregava estupefaciente para consumo do corréu, ambos custodiados em Penitenciária Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes Provas incriminatórias consistentes Testemunha arrolada pela Defesa que não infirmou as responsabilidades penais dos acusados - DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS VALIDADE Os testemunhos dos agentes penitenciários têm validade como quaisquer outros Depoimentos coerentes Condenação mantida Crimes configurados - Sentença condenatória mantida RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-SP - APR: 00105897920078260269 SP 0010589-79.2007.8.26.0269, Relator: Amado de Faria, Data de Julgamento: 15/12/2011, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/12/2011);

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES DENTRO DE UNIDADE PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - VALIDADE - FARTA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Estando provadas a materialidade e a autoria delitiva, verificando-se, ainda, o intuito de tráfico da droga apreendida dentro da unidade prisional, é devida a condenação do réu; 2. Os testemunhos de agentes penitenciários, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los; 3. Recurso não provido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 3690106 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 06/04/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2016);

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Prova inequívoca de que a ré tentou ingressar com maconha no estabelecimento prisional. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. O depoimento dos agentes da lei tem o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um decreto condenatório. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. Isentar-se o réu da multa prevista também é medida descabida, vez que não cabe ao julgador deixar de aplicar imposição legal. No juízo da execução é que a miserabilidade do condenado pode ser examinada para fim de ser concedida a isenção ou o parcelamento. Apelo improvido. (TJ-RS - APL: 70069660983 RS, Relator: Manuel José Martínez Lucas, Data de Julgamento: 24/08/2016, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2016).

Os elementos de prova encartados aos autos são aptos, seguros e suficientes para fundamentar a procedência do pedido. Conforme se evidenciou dos testemunhos prestados pelos agentes penitenciários, em razão da visita aos segregados, todas as pessoas passam pela revista, como medida de segurança. Com efeito, ao ser realizada a revista na acusada, através do scanner corporal, verificou-se que esta trazia consigo um corpo estranho em sua cintura, sendo encontrado em revista pessoal duas grandes porções de droga, que totalizam em torno de 39 gramas. Ao ser confrontada, a acusada confessou que estava transportando a substância entorpecente para o interior do estabelecimento prisional.

Em que pese a corré Gabriela afirme a existência de determinada pessoa que teria se apresentado como Mirian, entendendo que seu argumento não merece acolhimento, na medida em que se mostra em contradição com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Ressalto que a corré Gabriela ao ser ouvida, afirmou que na época dos fatos residia na cidade de Uberlândia e que vinha com certa frequência visitar o seu companheiro e corréu Edemir. Afirmou que não conhecia ninguém na cidade de Riolândia e que não

conhecia a pessoa que se apresentou com o nome de Mirian. Aduziu que essa pessoa se apresentou e disse que seu companheiro possuía uma dívida, e que, por isso, a corré deveria levar a substância para o interior da penitenciária para que houvesse a quitação do débito. Ocorre que a versão apresentada por Gabriela não encontra amparo nos demais elementos probatórios encartados aos autos, e afiguram-se contraditórios. Afirmou que não conhecia a pessoa chamada Mirian, mas mesmo assim atendeu aos seus pedidos e tentou adentrar no interior da penitenciária de posse das substâncias. Afirmou que não sabia que seu companheiro devia qualquer valor para qualquer pessoa, mas mesmo assim acreditou na versão de pessoa que sequer conhecia, para pagar uma dívida de seu companheiro que afirmou desconhecer que existia.

Os argumentos trazidos pela corré não merecem credibilidade. Aduziu que ficou com medo, pois a pessoa de nome Mirian a teria ameaçado e a forçado a adentrar na unidade de posse das substâncias. Ocorre que, em juízo afirmou que sequer conhecia a corré Mirian. Não é crível que a corré desse ouvidos a pessoa que não conhecia para adimplir uma dívida cuja existência desconhecia. Ademais, estava adentrando na unidade prisional, e poderia ter reportado eventuais ameaças que estivesse sofrendo para os agentes que lá se encontravam, ou ainda, buscado o auxílio da autoridade policial. Todavia, preferiu atender ao pedido de pessoa que sequer conhecia e arriscou-se adentrando no estabelecimento de posse dos entorpecentes. Ademais, não pode a corré ignorar a ilicitude de seu comportamento, pois visitava seu companheiro com frequência, e portanto, sabia das regras de ingresso na unidade prisional, e dos objetos que poderia levar para o interior da unidade.

De se salientar, inclusive, que na posse da corré foi encontrada uma carta com orientações de como adentrar na unidade prisional de posse das substâncias entorpecentes, bem como dados contábeis de uma facção criminosa. No ponto, a corré afirmou que desconhecia o teor da carta que portava. Ora, mais uma vez, suas palavras não merecem credibilidade. Não é crível que a corré não soubesse o teor das informações constantes da carta que transportava, que continha, inclusive, orientações de como adentrar na unidade de posse das substâncias, circunstância que a toda evidência demonstra que Gabriela agiu de forma premeditada, de forma consciente e voluntária na prática delitiva. Não merece acolhimento, portanto, a tese encampada pela defesa de que houve coação moral irresistível, posto que restou isolada no campo da retórica, sem amparo probatório.

Ademais, os relatos dos agentes penitenciários não apenas se mostraram revestidos de verossimilhança, como conservaram a coerência em relação à maneira como a apreensão da droga se operou. Em Juízo, afirmaram que o aparelho de scanner identificou que Gabriela estava de posse de um volume estranho na região de sua cintura. Ao pedirem para que a mesma explicasse o volume, a corré confessou que estava na posse das substâncias entorpecentes.

Por sua vez, a substância entorpecente encontrada com a corré só poderia ter como destinatário o corréu Edemir, já que a corré não conhecia outras pessoas na região, como afirmou em seu interrogatório, oportunidade em que, ainda, afirmou que visitava com frequência seu companheiro. No ponto, cito o depoimento prestado por Jurandir, quando afirmou que Gabriele disse que as substâncias eram destinadas para seu companheiro Edemir, e que deveriam ser entregues nas mãos deste. Entendo, portanto, que as substâncias entorpecentes, a toda evidência, destinavam-se ao corréu Edemir, única pessoa conhecida da corré Gabriela e que cumpria pena no interior da unidade pela prática do crime de tráfico de drogas. Incabível, portanto, o afastamento do art. 29, dada a relação de liame existente entre os corréus, que agiram em conjunto para praticar o delito objeto de análise.

Em suma, o acervo probatório é idôneo e comprova o envolvimento dos acusados na prática do crime, que com suas condutas, de trazer consigo e ocultar 39,32 gramas de maconha, incorreram na prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sabe-se que o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não sendo exigida a venda de entorpecente a terceiro para que ocorra a consumação deste delito. Nesse sentido, entende a jurisprudência:

Tráfico de entorpecentes. Réu que, submetido à revista para entrar em penitenciária a fim de visitar seu irmão, é surpreendido na posse de uma porção de maconha, com peso aproximado de 6,76 gramas, escondida em sua cueca. Prova oral hábil. Palavras dos agentes penitenciários coerentes e harmônicas. Circunstâncias da prisão evidenciando que a droga seria entregue para o consumo de terceiros e impossibilitando a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Versão do réu isolada e que não convence. Condenação de rigor. Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, bem reconhecida. Penas que não comportam reparo e já beneficiaram o acusado com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, inviável. Regime fechado necessário. Apelo improvido. (TJ-SP - APL: 00013310520158260224 SP 0001331-05.2015.8.26.0224, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 08/02/2017, 7ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/02/2017);

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006) SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS COM ESPECIAL RELEVÂNCIA JÁ QUE EMBASADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APREENSÃO DE CERCA DE QUARENTA E CINCO GRAMAS DE "MACONHA" ALOCADAS NO INTERIOR DA CAVIDADE VAGINAL DA INSURGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DEMONSTRAM O DOLO DE TRAFICÂNCIA NA CONDUTA PERPETRADA PELA APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª C. Criminal - 0039437-24.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 25.05.2020). (TJ-PR - APL: 00394372420198160014 PR 0039437-24.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2020).

Por sua vez, a Defesa não conseguiu demonstrar a falibilidade dos depoimentos das testemunhas, não logrando êxito em comprovar qualquer elemento de prova caracterizador de causa excludente da ilicitude ou culpabilidade. Ademais, considerando a quantidade da substância apreendida, 39,32 gramas, e a intenção de a inserir no interior do estabelecimento prisional, denota-se que se destinava à comercialização.

Saliento, por fim, que considerando que o crime ocorreu dentro de estabelecimento prisional, o grau de reprovabilidade da conduta dos acusados é maior. Quanto à acusada, entendo que deve ocorrer a majoração de sua pena em 1/3, que se mostra razoável e proporcional à gravidade de sua conduta, ao atentar adentrar em um estabelecimento que possui uma finalidade de ressocialização portando uma substância altamente lesiva e causadora de dependência física e psíquica. Por sua vez, a conduta do acusado Edemir é ainda mais reprovável, na medida em que cometeu o crime dentro do estabelecimento em que já cumpre pena, o que denota uma maior audácia do acusado, posto que nem mesmo a restrição de sua liberdade foi capaz de frear seu ímpeto criminoso, posto que continua a cometer crimes mesmo já estando a cumprir sanção penal. Assim, entendo por bem majorar a pena do acusado em metade, o que se mostra proporcional e razoável à gravidade de sua conduta, diante de seu total desrespeito pela figura do Estado e sua contumácia na prática de crimes. Por tais motivos, a pretensão punitiva procede.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI,

da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42).

No caso, o delito é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

DOSIMETRIA

GABRIELA RODRIGUES RAMOS

1ª FASE. PENA BASE

Na primeira fase, verifica-se que acusada é primária (fls. 156). Inexistem informações aos autos sobre sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias são inerentes ao crime. Por sua vez, a natureza e quantidade de droga corroboram a caracterização do tráfico, devendo ser valoradas na terceira fase e para a fixação do regime.

Consequentemente, a pena deve partir do mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

2ª FASE. PENA INTERMEDIÁRIA

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. A corré não confessou a prática do crime, tendo aduzido que estava na posse das substâncias entorpecentes por ter sido ameaçada e forçada a adentrar na unidade de posse das mesmas.

Considerando a ausência de confissão plena, deixo de considerar a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d” do CP.

3ª FASE. PENA DEFINITIVA

Na terceira fase, as circunstâncias do fato, ou seja, a expressiva quantidade de droga encontrada, a prática de tráfico no interior de unidade prisional e a existência de relacionamento íntimo de afeto duradouro com o acusado Edemir, pessoal para quem a substância se destinava indicam a prática do crime de tráfico de drogas. Presente a causa de aumento de 1/6 a 2/3 referente à prática de tráfico nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional (art. 40, III, da Lei 11.343/06). Como a acusada foi flagrada na posse de droga já dentro da unidade prisional (e não nas imediações), no momento da revista, sua conduta se torna mais reprovável, motivo pelo qual se justifica a aplicação da fração intermediária de aumento (1/3), o que resulta em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, pena que torno definitiva.

Considerando a primariedade da corré Gabriela, bem como a inexistência de elementos concretos que evidenciem sua dedicação na prática de atividades ilícitas ou envolvimento com organização criminosa, entendo ser possível a adoção da figura prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. Sobre o assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA PENA. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1 O TRIBUNAL REALIZOU INTERPRETAÇÃO JURÍDICA SOBRE O CASO, CONCLUINDO PELA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CASO CONCRETO, NOTADAMENTE POR CONSIDERAR A PRIMARIEDADE DO RÉU, QUE OSTENTA APENAS UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL, SEM TRÂNSITO EM JULGADO, AUSENTE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUE ELE SE DEDICAVA À ATIVIDADE ILÍCITA, OU INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, JUSTIFICANDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. 2 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR:

185418820188090175, RELATOR: DES. EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 15/08/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJ 2816 DE 27/08/2019).

Diante disso, reduzo a pena em 2/3, passando a dosar a pena definitiva em 2 (dois) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois dias-multa).

VALOR DO DIA MULTA

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Cabe reconhecer que o delito cometido na forma privilegiada não é equiparado a hediondo (HC 118553 do STF):

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida. (HC 118533, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016). Considerando a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, deve ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, na forma do art. 33, §2º, 'c', do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Em face do julgamento do HC nº 97256, da relatoria do Min. Ayres Britto, oriundo do egrégio Supremo Tribunal Federal, o qual afastou a vedação contida no art. 44, da Lei n.º 11.343/06, cabível a análise das condições pessoais da ré para fins de concessão da substituição da pena por restritivas de direito e a aplicação de regime inicial mais brando. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas

restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente. (HC 97256, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113 RTJ VOL-00220-01 PP-00402 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 279-333). Assim, no caso em apreço, entendo que encontram-se presentes os requisitos elencados nos incisos do art. 44, e § 2º, do Código Penal, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito que consistirão em: 1) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a ser estabelecido quando da execução da pena, pelo período da pena corporal; e, 2) prestação pecuniária, que fixo no patamar de 1 (um) salário mínimo. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DETRAÇÃO (art. 387, §§ 1º e 2º do CPP) A acusada responde ao processo em liberdade, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar no presente. Considerando que não respondeu ao processo em reclusão, não há que se falar na incidência do quanto disposto no art. 387, §2º, do CPP.

EDEMIR GONZAGA BATISTA NETO

1ª FASE. PENA BASE

Na primeira fase, verifico que acusado ostenta antecedentes, pois foi condenado nos autos do processo nº 0001283-61.2018.8.26.0185 por sentença que transitou em julgado no curso deste processo, por fato anterior ao apurado nestes autos, conforme se verifica de certidão constante de fls. 988 e 989 daquele processo. Inexistem informações aos autos sobre sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias são inerentes ao crime. Por sua vez, a natureza e quantidade de droga corroboram a caracterização do tráfico, devendo ser valoradas na terceira fase e para a fixação do regime. Diante do exposto, considerando os antecedentes do acusado, a pena deve se afastar do mínimo legal. Assim, exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 5 anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

2ª FASE. PENA INTERMEDIÁRIA

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena não se altera.

3ª FASE. PENA DEFINITIVA

Na terceira fase, as circunstâncias do fato, ou seja, a expressiva quantidade de droga encontrada, a prática de tráfico no interior de unidade prisional e a existência de relacionamento íntimo de afeto duradouro com a corréu Gabriela, indicam que a substância destinava-se à sua pessoa, denota a prática do crime de tráfico de drogas. Ademais, o acusado Edemir foi condenado recentemente por sentença transitada em julgado em razão da prática do crime de tráfico de drogas (certidão de fls. 204-205), o que indica sua dedicação à atividades criminosas, afastando, por conseguinte, a caracterização do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Presente a causa de aumento de 1/6 a 2/3, referente à prática de tráfico nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional (art. 40, III, da Lei 11.343/06). Considerando que o acusado praticou a infração enquanto estava recluso na unidade prisional, sua conduta se torna mais reprovável, motivo pelo qual resta caracterizada a causa de aumento a incidir na fração ½ (metade) de aumento, o que resulta em 8 (oito) anos, e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, pena que torno definitiva.

VALOR DO DIA MULTA

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Cabe reconhecer que o delito cometido é equiparado a hediondo (art. 2º da Lei 8.072/90 e Súmula 510 do STJ), mas a hediondez por si só não justifica a imposição de regime fechado (Tema 972 da repercussão geral do STF), surtindo efeitos apenas na esfera de execução da pena. Pelo montante da pena e pela reincidência, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, a, do Código Penal).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Pelo montante da pena (maior que 4 anos), incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (art. 387, §§ 1º e 2º do CPP)

O acusado responde ao processo preso por outro juízo, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar no presente. Portanto, o acusado faria jus ao direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não devesse ficar preso. No que tange à detração, considerando que o acusado cumpre pena por ordem de outro juízo, entendendo ser mais adequado que o juízo de execução proceda com a análise acerca da progressão de regime, em análise aos critérios objetivos e subjetivos para tanto.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e

provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR:

GABRIELA RODRIGUES RAMOS à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, que substituo por duas penas restritivas de direito consistentes em: 1) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a ser estabelecido quando da execução da pena, pelo período da pena corporal, nos termos do art. 46 do CP; e, 2) prestação pecuniária, que fixo no patamar de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput e §4º c. c. art. 40, III, da Lei 11.343/06 e art. 29, caput, do Código Penal;

EDEMIR GONZAGA BATISTA NETO à pena de 8 (oito) anos, e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, e pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c. c. art. 40, III, da Lei 11.343/06 e art. 29, caput, do Código Penal.

Custas pelos réus, observada a gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ), o mandado de prisão e, após, seu cumprimento, a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ; bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Expedida a guia, ela deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução mediante lançamento da movimentação "processo findo", com a situação "suspense" (art. 468, §3º, das NSCGJ), certificando-se nos autos. Após, nada mais restando a deliberar, archive-se.

P.I.C.

Paulo de Faria, 02 de Maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA